

0001222-85.2017.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

0001222-85.2017.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001222-85.2017.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos Farina e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

ANTONIO CARLOS FARINA, UBIRATAN GONÇALVES VELASCO "vulgo" Gustavo e HELENA RODRIGUES DOS SANTOS, já devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 171, "caput", c.c. artigo 16, ambos do Código Penal, porque no dia 03 de outubro de 2016, durante o período matutino, na Rua Jatobá, n.º 201, Jardim Mirante, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, agindo em conjunto e identidade de desígnios, obtiveram para si vantagem indevida, consistente em R\$ 35.000,00, em prejuízo de Edilvan Ribeiro Soares, induzindo-o em erro.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2019 (pág. 186/187 e 214).

Pelo(a) representante do Ministério Público foi oferecido aos réus HELENA e UBIRATAN, o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95 (pág. 226/227).

A ré HELENA constituiu advogado (pág. 69), foi citada (pág. 344/346) e peticionou concordando com o benefício (pág. 273/274). Na sequência, compareceu na audiência e concordou com as condições impostas (pág. 347/349).

O réu UBIRATAN constituiu advogada (pág. 113), foi citado (pág. 311) e apresentou defesa (pág. 236/244). Ele não compareceu na audiência de proposta da suspensão condicional do processo (pág. 347/349).

Na resposta à acusação argumentou a Defesa do réu UBIRATAN, em sede de preliminar, que a denúncia é inepta. No mérito, argumentou que não houve qualquer delito praticado pelo réu, uma vez que ele não negociou com a vítima, e ainda, que o dinheiro recebido por ele a título de comissão foi devolvido. Aduziu que sua conduta é atípica. Ao final, pugnou por sua absolvição e arrolou a mesma testemunha de acusação.

O réu ANTÔNIO foi devidamente citado (pág. 353/355) e constituiu advogado (pág. 358). Na sequência apresentou defesa (pág. 368/369).

Na resposta à acusação argumentou a Defesa do réu ANTÔNIO, que não há provas da materialidade ou autoria do delito. Ao final, arrolou oito testemunhas de defesa.

Em audiência de instrução, foi ouvida a vítima (pág. 480). Na audiência em continuação (pág. 568/569) foi interrogado o réu ANTONIO CARLOS FARINA (pág. 566/567) e decretada a REVELIA em face do réu UBIRATAN GONÇALVES VELASCO.

Em debates orais finais, o(a) representante do Ministério Público pugnou pela condenação do(s) réu(s) nos termos da denúncia. Por sua vez, as Defesas, em alegações finais escritas (pág. 570/573 e 574/578), pugnaram pela absolvição, com base na fragilidade probatória.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Dos Documentos:

Nos autos consta a portaria (pág. 03/04), o boletim de ocorrência (pág. 05/07), os comprovantes de pagamento (pág. 08/10), as notas promissórias (pág. 46/65), os recibos dos valores devolvidos (pág. 66/67), o termo de confissão de dívida (pág. 114/115), a SENTENÇA da ESFERA CÍVEL (pág. 245/251), os depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Do conjunto probatório:

Na fase policial, o réu ANTONIO CARLOS FARINA, assim aduziu:

“Que sobre os fatos aqui investigados, confesso que devo a quantia de R\$ 20.000,00 à pessoa de EDILVAN RIBEIRO SOARES, porém o valor estará sendo pago na esfera cível. Os fatos aqui investigados é meramente desacordo comercial”. O que foi ratificado em juízo. Em complemento esclareceu que ainda falta pagar o importe de R\$ 17.000,00 para a vítima. Que não conhecia a vítima antes dos fatos. Que está aposentado. Que Edilvan desistiu do negócio.

Por sua vez, o réu UBIRATAN GONÇALVES VELASCO, assim esclareceu na fase policial:

“Que ele tinha um escritório de intermediação de negócios, sendo que não era uma imobiliária. Que foi procurado por Antônio e Helena, os quais são corretores autônomos, mas não possuem uma imobiliária, e lhe propuseram o negócio acerca da venda da casa. Eles disseram que havia um cliente, a pessoa de nome EDILVAN, o qual

estava interessado na casa, e ele aceitou participar da negociação. Ficou estipulado que o cliente daria R\$ 35.000,00 de entrada, mais sua casa e um terreno, para a compra da outra casa. Ele ganharia R\$ 7.000,00 de comissão e Helena ganharia R\$ 3.000,00 de comissão, e não sabe dizer quanto Antônio ganharia. Aduziu que Antônio ficaria responsável de passar o valor da entrada para o dono da casa. Não sabe ao certo o que aconteceu, mas sabe apenas dizer que o negócio não se concretizou. Afirmou que o Edilvan não cumpriu a parte dele, porque não vendeu sua casa e seu terreno, e que Antônio também não repassou a entrada ao dono da casa. Que Edilvan o procurou e ele devolveu o valor recebido de R\$ 7.000,00, pois não fez nada de errado. Que não sabe dizer, o porquê Antônio não devolveu o valor ao cliente. Que não sabe dizer onde ele está morando, e tentou contato com ele para resolver a situação de forma amigável, mas não teve êxito”.

Na sequência, a ré HELENA RODRIGUES DOS SANTOS, assim informou na fase policial:

“Que exerceu a profissão de corretora de imóveis. Na época dos fatos o EDILVAN lhe procurou, solicitando seus serviços para comprar uma casa. Então eu contatei alguns colegas da área e encontramos uma casa que agradava o cliente. Antônio e Ubiratan estavam na negociação. Que Antônio tinha uma casa no valor de R\$ 260.000,00, e o cliente deu R\$ 35.000,00 de entrada. Daria também uma casa e um terreno, e financiaria o restante. Como eu apresentei o cliente ao ANTÔNIO, recebi a comissão de R\$ 3.000,00, e não sei dizer qual seria a comissão de ANTÔNIO. O imóvel era de Antônio, como corretor. Quando a negociação não se concretizou, e o cliente lhe procurou, ela devolveu os R\$ 3.000,00 que havia recebido de comissão. Tentando ajudar o cliente, conversou com ANTÔNIO e UBIRATAN, sabendo que UBIRATAN devolveu o dinheiro recebido de comissão. Soube que ANTÔNIO devolveu parte do dinheiro, e então pediu que ele assinasse notas promissórias para o EDILVAN, o qual não quis recebe-las. Depois disso ANTÔNIO desapareceu. Aduziu que não teve qualquer intenção de prejudicar ou enganar o EDILVAN, no entanto, que devolveu o valor recebido de comissão. Não sabe dizer, o porquê o negócio não se concretizou. Apenas apresentou o EDILVAN aos corretores, para que realizassem a transação”.

A vítima EDILVAN RIBEIRO SOARES, assim relatou na fase policial:

"Que conhecia a pessoa de Helena já há algum tempo, sabendo que ela era corretora de imóveis. Que procurou por ela, pois estava querendo adquirir uma casa maior. Que Helena disse que arrumaria tal casa, sendo que depois de um tempo Helena disse que tinha conseguido uma casa para ele, tendo ele ido visitar a casa, que custava R\$ 260.000,00. Que ele gostou da casa e se interessou pelo negócio, sendo que ficou acertado dele dar um valor de entrada, mais a casa dele e um terreno como pagamento, além de mais R\$ 45.000,00 em dinheiro. Que eram três corretores que estavam tratando com ele, sendo Helena, Gustavo e Antônio. Que ele chegou a dar R\$ 35.000,00 de entrada, sendo que nada de receber a casa. Que depois Antônio ficava insistindo que ele passasse logo o terreno para o nome dele, pois já tinha um comprador interessado. Que ele desconfiou e não passou nem o terreno e nem a casa dele, pois ainda não tinha se mudado para a nova casa. Que depois acabou descobrindo que a casa que pretendia comprar já havia sido vendida para outra pessoa. Que Antônio mentia e dizia que não tinha passado a casa para ele, pois a casa estaria comprometida e iria arrumar outra casa para o declarante. Que ele soube, que na verdade Antônio, Helena e Gustavo receberam os R\$ 35.000,00 dele, mas não repassaram nada para o dono da outra casa, assim, já que nada recebeu, o dono da outra casa vendeu o imóvel. Que quando procurou por Antônio, Helena e Gustavo, estes tentaram enrolá-lo, sendo que chegou até mesmo a ser destratado por Antônio. Que Gustavo, Helena e Antônio chegaram a devolver parte do dinheiro que ele deu como entrada, sendo que Antônio devolveu R\$ 5.000,00, tendo Helena devolvido R\$ 3.000,00, e Gustavo devolveu R\$ 7.000,00, totalizando R\$ 15.000,00. Que depois disso não teve mais nenhum centavo de volta, sendo que muito insistiu, mas nada de reaver o restante do dinheiro. Que por último Helena e Gustavo procuraram por ele, oferecendo algumas notas promissórias (10 no total), no valor de R\$ 2.000,00 cada

uma. Que Helena e Gustavo diziam que só entregariam as promissórias se ele visse na delegacia retirar a queixa contra eles, tendo ele dito que não faria isso. Que ele disse que não aceitaria as promissórias, sendo que mesmo assim Gustavo acabou entregando-as. Que antes de sair Gustavo teria dito que não aconteceria nada com ele na delegacia, pois ele conhecia os investigadores e delegado daqui. Que apresenta as 10 notas promissórias que lhe foram entregues. Que foi até o endereço constante nas promissórias, que seria de Antônio, mas acabou descobrindo que ele não se encontra lá. Que no local existe um estacionamento, onde o dono disse que há três anos Antônio teve uma imobiliária no local, mas que não mais está lá, pois fora despejado. Que o dono do estacionamento ainda disse, que muita gente e intimações vão até lá procurando por Antônio, o qual aplica diversos golpes pela região. Que por fim, informa que ainda se encontra no prejuízo, pois não lhe devolveram os R\$ 20.000,00, tendo ficado sem o dinheiro e sem poder comprar outra casa". O que foi ratificado em juízo. Em complemento esclareceu que queria uma casa maior, e tinha um terreno. Então conheceu primeiro a HELENA, que iria vender o seu terreno. Daí apareceu essa casa, e os três vieram com a proposta. Eu dei a entrada no valor de R\$ 33.000,00 para o FARINA, e depois dei mais R\$ 2.000,00. A proposta era boa. O FARINA queria que eu passasse minha casa e meu terreno para o nome dele. Eles iriam me deixar sem nada. Depois começaram a me falar que a casa tinha problemas estruturais, e iam encontrar outra casa para mim. Depois soube que a casa havia sido vendida para outro. Apareceu outro indivíduo, que ia pegar o meu terreno, em troca de uma dívida com esse FARINA. Liguei para o FARINA, o qual começou a me maltratar. Eu fui no endereço da imobiliária, e lá tinha um estacionamento de carros. O dono do local me disse que várias pessoas iam lá atrás do FARINA. Me disseram que o FARINA estava aplicando o golpe nas pessoas. A HELENA participou de toda a negociação. O FARINA disse que ia procurar outro imóvel, mas eu disse que queria apenas o dinheiro de volta. O FARINA me mostrou o comprovante, que tinha depositado um dinheiro na conta do VELASCO. Eu consegui pegar R\$ 7.000,00 do VELASCO, R\$ 3.000,00 da HELENA e depois R\$ 5.000,00 do FARINA. Eu ia atrás do FARINA, mas ele trocou de número. No total, me devolveram a quantia de R\$ 15.000,00. Depois que fiz o BO, apareceram na minha casa o VELASCO e HELENA com 10 promissórias, no valor de R\$ 20.000,00, assinadas pelo FARINA. Eu entrei com ação na esfera cível contra eles em Campo Limpo Paulista. Foi a HELENA quem disse que essa outra casa havia sido vendida. Eles pegaram o dinheiro e não repassaram para o dono. Eu sou operador de empilhadeira. Eu tenho o ensino médico completo. Foi o FARINA quem assinou o documento. Eles queriam logo assinar do documento, dizendo que caso contrário, eu perderia o negócio. Eu tenho apenas uma casa e um terreno. Nunca foi de ficar comprando outros imóveis. Eu não desisti do negócio, o FARINA disse que a casa estava comprometida, e que iria procurar outra casa. Ele não disse, que o proprietário da casa, não iria esperar que eu vendesse a minha casa. O VELASCO e HELENA veio com as promissórias assinadas por FARINA. Eu disse que não queria as promissórias. Eles disseram que me dariam, se eu retirasse o BO, e eu disse que não faria isso. O FARINA me mostrou um comprovante no valor de R\$ 7.000,00, do valor que havia repassado ao VELASCO, e este me devolveu tal valor.

Dos Depoimentos da Vítima:

Não há razões para que os depoimentos prestados pela vítima sejam acolhidos com reserva, já que "em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACrim - Ap. n°. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.7.86 - Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações da vítima.

Do Crime de Estelionato:

Os réus ANTÔNIO, UBIRATAN e HELENA foram denunciados, porque no dia 03 de outubro de 2016, durante o período matutino, na Rua Jatobá, n.º 201, Jardim Mirante, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, agindo em conjunto e identidade de desígnios, obtiveram para si vantagem indevida, consistente em R\$ 35.000,00, em prejuízo de Edilvan Ribeiro Soares, induzindo-o em erro.

Com relação à ré HELENA, houve o oferecimento e aceitação do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95.

Passo ao julgamento do mérito em relação aos réus ANTÔNIO e UBIRATAN.

Vale aqui salientar, que a Lei n.º 13.964/2019, inseriu o § 5º, no artigo 171, do Código Penal, disciplinando que referido delito somente se procede mediante representação. Diante desse novo cenário, a vítima em JUÍZO (pág. 476/478), manifestou expresso interesse em representar contra os réus, sanando qualquer nulidade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo

entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. 4. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido. 5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal. Além disso, não é socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo o tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade. 6. Habeas corpus não conhecido. (HABEAS CORPUS Nº 573.093 - SC (2020/0086509-0) RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA - STJ - Julgamento: 1º de junho de 2020).

No que tange ao delito, o artigo 171, “caput”, do Código Penal, assim disciplina:

“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis”.

Ao invés da clandestinidade, da violência física ou da grave ameaça, o agente, no estelionato, emprega o engano, a astúcia, o engodo, sem alarde ou estrépito.

O estelionato é o crime patrimonial mediante fraude, é a forma evoluída de captação do alheio.

Para configuração do estelionato, portanto, o agente, num primeiro momento (de início), deve empregar artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Artifício pode ser definido como uma certa encenação material, com a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima, isto é, o agente com determinado “mis en scène” ou estratagema provoca ou mantém em erro a vítima.

Ardil é a conversa enganosa; já não se trata da fraude material, mas a intelectual. Entretanto, a diferença entre artifício e ardil, em face de nossa legislação, é de valor relativo, já que, logo após mencioná-los, o legislador empregou a fórmula genérica ou qualquer outro meio fraudulento; isto é, nessa fórmula estão, sem dúvida alguma, incluídos o artifício e o ardil.

De outra parte, o meio iludente empregado pelo agente deve ser idôneo, isto é, apto a enganar a vítima; se, desde o início, o meio já se mostrava absolutamente ineficaz para iludir o sujeito passivo, é o caso de crime impossível, não caracterizando, assim, o estelionato.

“Se desde o início da 'mise-en-scène' a vítima percebeu que se tratava de uma malandragem do acusado, à evidência de ter ocorrido na espécie inidoneidade absoluta do meio empregado, a desnaturar a figura do estelionato, configurando delito impossível” (TACRIM-SP - AC - Rel. Toledo de Assumpção - RT 418/262).

Para caracterização do estelionato, a doutrina, de forma quase majoritária, entende necessário o dolo genérico, isto é, a vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém, e o dolo específico, que a intenção de tornar-se dono da coisa.

O dolo deve, também, ser anterior (antecedente, preordenado) ao uso da fraude e à obtenção da vantagem ilícita, pelo erro da vítima (se posterior, há crime de apropriação indébita).

“O dolo necessariamente antecede à obtenção da vantagem indevida, de tal modo que, se, em dado caso, o dolo só incidiu depois daquela obtenção, é juridicamente impossível cogitar-se do delito” (TACRIM-SP – AC – Rel. Gonzaga Franceschini – RT 692/287). Ainda nesse sentido: RT 434/370, 430/366, 419/290.

O estelionato é um crime material, e assim, a consumação se dá quando ocorre a produção do resultado, ou seja, o crime se consuma no momento em que o agente consegue obter a vantagem ilícita, em prejuízo da vítima.

“No estelionato típico, o crime consuma-se no momento em que a vítima é desfalcada em seu patrimônio e o agente obtém a vantagem indevida” (TACRIM-SP – Ver. – Rel. Hélio de Freitas – JUTACRIM 87/24).

“O estelionato é crime material de dano, tendo o seu momento consumativo quando obtém o agente indevida vantagem patrimonial após ilaquear a boa-fé da vítima” (TACRIM-SP – HC 131.038 – Rel. Renato Mascarenhas).

No caso em tela, é certo que o delito de estelionato atingiu sua consumação.

Em seu depoimento a vítima esclareceu que procurou a corretora de imóveis HELENA, pois pretendia comprar uma casa maior. Esta lhe apresentou os réus ANTÔNIO e UBIRATAN, sendo que ANTÔNIO tinha uma casa, a qual lhe interessou, pelo valor de R\$ 260.000,00. Então lhes deu a entrada do valor de R\$ 35.000,00, e ainda daria sua casa e um terreno como forma de pagamento. Contudo, depois soube que o negócio não se concretizou, tendo em vista que os réus dividiram o valor dado a título de entrada entre eles, e não repassaram ao proprietário da casa, que acabou vendendo o imóvel para outra pessoa. Aduziu que HELENA lhe devolveu a quantia de R\$ 3.000,00, o UBIRATAN a quantia de R\$ 7.000,00, e ANTÔNIO a quantia de R\$ 5.000,00, restando ainda um prejuízo de R\$ 20.000,00.

A ré HELENA esclareceu que a vítima lhe procurou, pois queria uma casa maior, então ela falou com colegas da área e encontraram uma casa, a qual era do corretor de imóveis ANTÔNIO. Pela apresentação, ela ganhou a comissão de R\$ 3.000,00, mas quando o negócio não se concretizou, ela devolveu tal quantia à vítima. Aduziu ainda, que tentou de todas as formas contato com ANTÔNIO, para que resolvesse a situação e devolvesse toda a quantia à vítima, contudo, não conseguiu mais contato com o corretor de imóveis, e ainda, não sabe dizer o porquê o negócio não se concretizou.

O réu UBIRATAN esclareceu que HELENA e ANTÔNIO lhe procuraram para intermediar a negociação da venda do imóvel à vítima, e para tanto ele recebeu a comissão de R\$ 7.000,00, mas quando o negócio não se concretizou, ele devolveu o valor à vítima. Não sabe dizer o que aconteceu, e o porquê o réu ANTÔNIO não devolveu todo o valor à vítima.

O réu ANTÔNIO confessou que deve à vítima o valor de R\$ 20.000,00, e que a situação refere-se apenas e tão somente a desavença comercial, não tendo qualquer relação com a esfera criminal.

Com relação ao réu UBIRATAN, as provas são frágeis quanto ao fato da prática do delito em comento. Ao que se constatou ele se limitou a fazer a intermediação para o negócio e obteve a quantia de R\$ 7.000,00 a título de comissão, o que foi devolvido, quando a transação não se concretizou. É ainda de se observar, que o valor foi depositado em nome do réu ANTÔNIO (pág. 08/10). Por fim, a própria sentença na esfera cível (pág. 245/251), não reconheceu a legitimidade do réu

UBIRATAN no negócio jurídico. Portanto, é de rigor sua ABSOLVIÇÃO.

Com relação ao réu ANTÔNIO, o acervo probatório constante nos autos demonstra que ele recebeu o valor de R\$ 35.000,00 da vítima, pagou as comissões aos réus UBIRATAN e HELENA, mas de forma DOLOSA não repassou qualquer valor ao proprietário do imóvel, fazendo com que o negócio jurídico não se concretizasse. O réu ANTÔNIO ainda ficou com R\$ 20.000,00 da vítima, causando-lhe considerável prejuízo.

O réu é reincidente específico nesse tipo de crime, e após a data dos fatos destes autos, veio a ser condenado em diversos outros, pelo mesmo delito de ESTELIONATO, conforme certidão de pag. 402/407.

Diante do exposto, restou comprovada a materialidade do crime de estelionato, bem como a autoria do réu ANTÔNIO CARLOS FARINA.

Passo à dosimetria da pena:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é REINCIDENTE (pág. 402/407), autos 0000448.36.2011.8.26.0115, que tramitou perante a 2ª Vara Judicial de Campo Limpo Paulista, com trânsito em julgado em 23/11/2015, o que será considerado na segunda fase de aplicação da pena. Além disso, a certidão de pag. 402/407 demonstra claramente a sua periculosidade, pois conta com diversas condenações por crimes contra o patrimônio. Também está claro que o réu agiu com muita frieza para o fim de lograr êxito em seu intento, indicando personalidade desvirtuada. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, qual seja: 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 402/407), que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO, fato que agrava ainda mais a situação e autoriza a majoração em 1/3. Entretanto, é ainda de se observar a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, considerando que o réu atualmente encontra-se com 72 anos de idade, conforme documento de identificação à pág. 487, eis que nascido em 06/05/1949, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, resultando em: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que "atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo". Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que "a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica".

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, "na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza'".

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada". (HC 101918/MS - Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)".

Nesse sentido:

MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inoportunidade no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como a apreensão das drogas em posse dos réus; a tentativa de empreender fuga em conhecido ponto de venda de drogas; dão a necessária certeza de que a droga destinava-se ao comércio espúrio tipo congruente. PENA primeira fase pena-base majorada em 2/5 ante a natureza da droga apreendida manutenção segunda fase aplicada a agravante da reincidência específica, aumentando a pena em 1/3 - manutenção - não há atenuantes terceira fase não há causas de aumento inaplicável o redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ante a reincidência do réu. REGIME fechado réu reincidente específico regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa negado provimento. (Apelação n.º 0011580-72.2017.8.26.0635 - 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relator: Laudo Mens de Mello - Julgamento: 28/02/2019).

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

No caso em tela, não cabe a aplicação da redução de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, conforme requerido pela DEFESA, considerando que o réu não reparou todo o dano suportado pela vítima.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Considerando que o réu é REINCENTE ESPECÍFICO, conforme certidão de objeto e pé de pág. 402/407, fato que demonstra sua personalidade voltada à criminalidade, nos termos artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO.

Anoto que o entendimento sumular do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial semiaberto para reincidentes cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 04 (quatro) anos.

Súmula nº 269: "É admissível a adoção de regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

E mais: "O regime inicial aberto não é hábil a apenação de agente reincidente, de acordo com o artigo 33, "c", do Código Penal, sendo possível se a reprimenda não for superior a 8 anos, a concessão de regime semiaberto". (RJDTACRIM 31/268).

Nessa linha, ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2º, C, DO CP. REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no AREsp 295009 MG 2013/0052517-7. Relator: Des. Maria Thereza de Assis Moura. julgado: 06/08/2013).

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena - Sursis, conforme dispõe o artigo 44, inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente.

Da pena pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério Público, para fins de:

a) CONDENAR o réu ANTÔNIO CARLOS FARINA, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 171, "caput", do Código Penal à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente SEMIABERTO e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor mínimo legal;

b) ABSOLVER o réu UBIRATAN GONÇALVES VELASCO, já devidamente qualificado nos autos, da imputação prevista no artigo 171, "caput", c.c. artigo 16, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o réu ANTÔNIO CARLOS FARINA está respondendo ao presente processo em liberdade, nada há que justifique a decretação de sua prisão neste momento.

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu ANTÔNIO CARLOS FARINA no rol dos culpados.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Paulista, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.